

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO - SESSÃO DE 12-03-2025 – MUNICIPAL
PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO

=====
Processos: TC-020974.989.24-6 e TC-020976.989.24-4 (Ref.: TCs-16186.989.24-0 e 16227.989.24-1).

Recorrente: Fundação do ABC – FUABC.

Assunto: **Pedidos de Reconsideração** contra o acórdão do Plenário do Tribunal de Contas que considerou parcialmente procedentes as representações contra o edital do Pregão Presencial nº 02/2024, elaborado pela Recorrente, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento, implementação, administração e fornecimento de vales alimentação, vale refeição, para atender funcionários e compras corporativas para a Fundação do ABC, sua mantida e suas unidades gerenciadas”*.

Responsável: Luiz Mário Pereira de Souza Gomes (Presidente)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP nº 288.403), Paulo André Simoes Poch (OAB/SP nº 181.402) e Flávio Santos da Silva (OAB/SP nº 342.519).

=====

EMENTA: EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. CRITÉRIO DE DESEMPATE POR VOTO DOS SERVIDORES. ADOÇÃO DA FORMA PRESENCIAL DO PREGÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ALTERAR O DECISÓRIO. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

01 – RELATÓRIO

1.1 Em exame **Pedidos de Reconsideração** interpostos pela **FUNDAÇÃO DO ABC – FUABC**, contra a decisão plenária de 04-09-2024, que julgou parcialmente procedentes as impugnações em face do edital do Pregão Presencial nº 02/24, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento, implementação, administração e fornecimento de vales alimentação, vale refeição, para atender funcionários e compras corporativas para a Fundação do ABC, sua mantida e suas unidades gerenciadas”*.

Naquela oportunidade, o E. Tribunal Pleno determinou à Administração que adotasse as medidas corretivas pertinentes para dar cumprimento à lei, em especial:

- “a) permitir a apresentação de rede “própria ou credenciada ou arranjo aberto para utilização de cartões bandeirados”;*
- b) observar os critérios de desempate estabelecidos nas normas vigentes;*
- c) reavaliar a rede credenciada exigida, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem exceder o necessário para satisfazer à demanda;*
- d) adequar o pagamento às normas da contabilidade privada, sem prever prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga do benefício;*
- e) adotar a forma eletrônica de pregão, ou justificar adequadamente a opção pelo formato presencial;*
- f) excluir a exigência de certidão negativa de recuperação judicial.*

1.2 Inconformada com a decisão, a **FUABC** interpôs **PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO** especificamente em relação ao critério de desempate estabelecido e à opção pelo formato presencial do pregão.

No que tange ao aludido critério, que envolve a votação dos servidores para a escolha da empresa vencedora, sustentou ser ele objetivo, citando, como exemplo, precedente do Tribunal de Contas da União que

reconheceu a possibilidade do uso deste método para desempate de propostas (TCU - RP: 4592023, Relator: MARCOS BEMQUERER, Data de Julgamento: 15/03/2023).

Defendeu que a escolha por votação dos funcionários é uma forma de garantir que a proposta mais vantajosa seja selecionada, considerando serviços de valor agregado, inovação tecnológica e sustentabilidade.

Outrossim, garantiu ser *“correta a previsão editalícia no sentido de que, uma vez superados os critérios legais do art. 60 da Nova Lei de Licitações é possível que seja realizado escrutínio com os funcionários para a escolha que ora se pretende, desde que seja previsto de forma objetiva e impessoal no edital como isso será realizado, estando esta escolha adstrita ao Poder Discricionário da Administração”*.

Também rebateu a alegação de que a escolha da modalidade presencial para a licitação afrontaria o §2º do art. 17 da Lei federal nº 14.133/2021, eis que o dispositivo permite a realização de licitações desta forma, desde que motivada, e que a palavra "preferencialmente" não deve ser confundida com "obrigatoriamente".

Ademais, assegurou que o pregão será gravado e filmado, cumprindo assim as exigências legais, de modo que a escolha pela modalidade presencial não infringe a legislação vigente.

1.3 O Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, por seu desprovimento.

Compreendeu que o desempate de propostas por meio de votação está em desconformidade com a legislação vigente, pois desconsidera os critérios previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, inclusive aqueles estabelecidos pela LC 123/06.

Ademais, pontuou que, *“não sendo o caso de disputa entre microempresa ou empresa de pequeno porte e de licitante que não possua as mesmas qualificações, e a despeito de a proibição de oferta de taxa de*

administração negativa impossibilitar a aplicação da “disputa final” (inc. I do art. 60), os subsequentes critérios de desempate (demais incisos do art. 60) e de contratação preferencial (art. 60, § 1º), na ordem legal estabelecida, são de observância obrigatória”.

Outrossim, ressaltou que a utilização da forma presencial de disputa deve ser devidamente motivada, por expressa previsão legal (art. 17, § 2º, da Lei 14.133/21).

Ponderou, ainda, que a modalidade presencial pode criar obstáculos ao acesso de interessados distantes, reduzindo a competitividade, assim como ocasionando ônus financeiros desnecessários devido à obrigatoriedade de gravação da sessão em áudio e vídeo.

1.4 A **Secretaria-Diretoria Geral** acrescentou que, ao contrário do afirmado nas razões recursais, o subitem 11.4¹ do edital “*prevê, como único critério de desempate entre as propostas, a votação dos servidores, não indicando o direito de preferência das Micro e Pequenas Empresas e, tampouco, que esse mecanismo somente será acionado após a superação dos critérios legais previstos no artigo 60 da Lei nº 14.133/21*” (grifo no original).

Quanto ao uso da forma presencial do pregão, adicionou que, “*ainda que se considere que referida decisão está inserida na esfera da discricionariedade da Administração, e mesmo não sendo o formato eletrônico obrigatório, a opção feita, consoante prescrito no § 2º do artigo 17 da Lei de Licitações, deve ser devidamente motivada, cuidado não adotado pela Fundação do ABC no presente caso*”.

É o relatório.

¹ 11.4. A empresa habilitada nos critérios de julgamento pré-estabelecidos neste edital, automaticamente irá para o desempate o qua (sic) se dará por meio de votação

2. PRELIMINAR

2.1 O v. acórdão foi publicado no D.O.E. de 12-09-2024 e os recursos interpostos em 03-10-2024 (eventos 54 do TC-016186.989.24-0 e TC-16227.989.24-1). Tempestivos, portanto.

2.2 Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, voto pelo **conhecimento**.

3. VOTO

3.1 A decisão combatida deve ser mantida, porquanto as razões recursais não prosperam.

3.2 Apesar de todo o esforço argumentativo da recorrente, impende destacar que o decisório, quanto aos dois aspectos combatidos, apropriadamente consignou:

“2.4 No que tange à votação entre os colaboradores como critério de desempate, entendo não possuir a cláusula amparo legal.

Desta forma, na companhia do MPC, considero que o edital deve ser corrigido, observando-se ‘os critérios de desempate estabelecidos pelo art. 60 da Lei 14.133/21, dando primazia ao direito de preferência conferido às microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com a LC 123/06’.

(...)

2.7 Além disso, o artigo 17, § 2º, da Nova Lei de Licitações estabeleceu o uso preferencial da forma eletrônica nas licitações, sendo ‘admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada’.

No caso, na linha do decidido por este Plenário em sessão de 03- 07- 24², considero que ‘a falta de justificativas suficientes para a utilização

² TC-011987.989.24-1. Relator Conselheiro DIMAS RAMALHO.

da forma presencial no presente caso impõe o reconhecimento da procedência da representação”

Ora, o decidido, destacou a falta de amparo legal para o critério de desempate adotado, assim como apontou, na linha do parecer da SDG, que, *“sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, deve ser obedecida a ordem estabelecida no artigo 60 da Lei nº 14.133/21”*.

Tal entendimento, aliás, se coaduna o posicionamento adotado nos autos do TC-012996.989.23-2³, citado pela SDG em sua manifestação, cujo trecho de interesse destaque:

“Colho ainda, no precedente jurisprudencial arrolado excerto referente à **impossibilidade de utilização de sorteio como critério de desempate**, para certames regidos pela Lei nº 14133/2021:

Dando seguimento, e avançando na lista de desempate alinhavada no edital, caso opte por certame regido pela Nova Lei de Licitações, a Administração não pode empregar o sorteio como parâmetro para adjudicar o objeto.

Com efeito, **o artigo 60 e respectivos §§ da Lei Federal n.º 14.133/2021 estabelecem lista fechada e sequencial para solução de igualdades (decorrentes das expressões ‘serão utilizados’ e ‘nesta ordem’), a qual deve ser rigorosamente obedecida, não estando a sorte entre as possibilidades estipuladas.**

Nem se argumente que essa escolha como fator de discriminação pode ser legitimada por empréstimo de mecanismo da Lei Federal n.º 8.666/93, uma vez que o § 2º do artigo 191 do Novo Diploma Licitatório veda a combinação dessas normas.

Importa salientar, antes de concluir, que **não se desconhecem as dificuldades experimentadas pelos órgãos e entidades públicas para realização de contratações de vale alimentação após a proibição de oferta de taxas negativas, o que não autoriza, no entanto, sejam adotadas regras divorciadas dos ditames legais.**

Nessas circunstâncias, **considerando inviáveis ou inadequadas as previsões de desempate** contidas nos subitens 8.21.1 e 8.21.2 acima transcritos, para empresas não qualificadas como ME’s e EPP’s, **resta seguir os demais critérios estabelecidos**

³ Sessão Plenária de 19-07-2023, relatora Conselheira de Castro Moraes

no dispositivo, porquanto guardam fundamento no artigo 60 da norma de regência.” (grifos da SDG)

Outrossim, não socorre a Recorrente o posicionamento adotado no mencionado acórdão do Tribunal de Contas da União, eis que esta Corte não se submete às decisões daquele Órgão.

Destarte, inexistente motivo para alterar o julgado neste aspecto.

3.4 De igual modo, as razões recursais deixaram de apresentar justificativas aptas a convalidar o emprego do formato presencial do pregão, nos termos do que determina o artigo 17, § 2º, da Lei nº 14.133/21.

Como destacou o MPC, a Recorrente limitou-se a sustentar que *“o dispositivo invocado não veda a realização do pregão de forma presencial, não podendo confundir a palavra ‘preferencialmente’ com ‘obrigatoriamente’”,* porém ignorando que o uso desta modalidade *“deve vir, por expressa previsão legal, motivada”,* o que não ocorreu.

O Órgão Ministerial também suscitou que, *“além de criar obstáculos ao acesso de interessados que estejam em local distante, reduzindo a competitividade da disputa, a gravação da sessão em áudio e vídeo – a ser obrigatoriamente adotada, caso se opte pela formatação presencial da licitação – traz desnecessários ônus financeiros à contratação e, por isso, deve ser efetivamente sopesada na fase de planejamento”.*

Assim, não há como acolher o apelo neste ponto.

3.5 Ante o exposto, e por tudo o mais consignado nos autos, meu voto **NEGA PROVIMENTO** aos Pedidos de Reconsideração.

Sala das Sessões, 12 de março de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO